

1500441-28.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... brigava na rua, ameaçaram lhe arrumar um tráfico. Enfatizou que quer tratamento. Admitiu que foi acusado de tráfico, assalto e injustamente de ter agredido a ex esposa.

A testemunha Luciano afirmou ter informações de que o réu morava em Florínea, vinha para Assis comprar drogas para revender naquela localidade. Relatou que o abordou e encontrou na cueca do Gilson crack e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500441-28.2021.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500441-28.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066991/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 16673539 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 1069/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2066991 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Gilson Martins, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal. Narrou que em 09/03/2021, por volta das 9h, na Rua Vereador David Passarinho, n.º 1.080, Vila Marialves, nesta cidade e Comarca, Gilson trazia consigo 50,58 g de crack e 23,69 g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar. Apurou-se que Gilson trazia consigo, na via pública, em sua cueca, saco plástico contendo relevantes pedaços de crack e um pedaço de maconha; policiais militares foram informados sobre a vinda de Gilson até Assis para comprar drogas e revendê-las em Florínea; com ele encontraram as drogas, R\$ 622,30 e um celular.

Notificado, o réu apresentou resposta a acusação (fls.194/197).

A denúncia foi recebida em 26/03/2021 e foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental do réu (fls. 211/213).

Foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 258/261).

O laudo pericial foi juntado e homologado nos autos em apenso.

O douto membro do Ministério Público apresentou alegações finais, nas quais pediu a condenação do réu. Sustentou que: policiais abordaram o réu por denúncia de que pessoa com a roupa que ele usava veio a Assis adquirir drogas; com ele foram apreendidos dinheiro e drogas em quantidade e forma de acondicionamento incompatível com a alegação de posse para consumo; no incidente para apurar a dependência apurou-se que a compreensão do caráter ilícito do fato e sua autodeterminação não estavam minimamente influenciadas à época da conduta; a pena deve ser aumentada pelos antecedentes criminais e o alto poder vulnerante de parte da droga apreendida, o crack; incide a agravante genérica da reincidência específica e a agravante de crime perpetrado durante o estado de calamidade pública; incabível a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 pela reincidência; o regime inicial deve ser o fechado, vedadas quaisquer outras benesses legais (fls. 291/299).

A douda Defesa pleiteou a absolvição do réu, sob os argumentos de que: a demora de mais de um ano para a realização da perícia implicou em cerceamento de defesa porque o réu ficou preso e em abstinência nesse período e, à época do exame, já não mais estava sob efeito das drogas e nem sofrendo transtorno mental pelo uso contumaz de entorpecentes; a demora no exame e a prisão preventiva durante esse tempo representam constrangimento ilegal; os depoimentos dos policiais devem ser desconsiderados porque são praticamente idênticos, demonstrando que foram ouvidos um na presença do doutro e houve parcialidade; a testemunha Valéria disse que trabalha como Técnica de Enfermagem na UBS de Florínea, conhece Gilson há 10 anos e tem conhecimento que ele é usuário contumaz de drogas; nenhuma testemunha viu o réu vendendo drogas; o dinheiro que estava com ele proveio da venda da parte que ele tinha de uma chácara herdada dos pais; cabe a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio; subsidiariamente, a pena deve ser reduzida em 2/3 pelo tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 e deve ser concedida a liberdade para o acusado (fls. 303/308).

A Defesa peticionou para corrigir erros materiais nos memoriais (fl. 309).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls.06/08), auto de exibição e apreensão (fl.09), laudo de constatação (fls. 47/51) e laudo de exame químico de entorpecente (fls. 228/230). Extraí-se do laudo pericial que foram periciados substância pulverizada e fragmentos vegetais, com resultado positivo para cocaína e Tetrahidrocanabinol (THC), substâncias de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório Gilson negou o crime. Afirmou que a droga apreendida era sua, usa crack faz muitos anos, é dependente químico e não consegue ficar sem fumar.

Relatou que estes dias teve convulsão e foi parar no hospital, quando fica sem, fica meio ruim e não consegue comer. Mencionou que fuma baseado para ver se consegue comer comida. Declarou que começou a usar maconha em 1985, fuma dia e noite sem parar, ficava sem dormir a noite inteira, como não tinha mais ficou apavorado e pegou o ônibus para comparar em Assis. Falou que na Vila Prudenciana

perguntou quem tinha para vender. Salientou que queria comprar uma quantidade para fumar um tempo, não podia sair de casa por causa do Coronavírus. Narrou que na hora que ia pegar o ônibus para Florínea foi abordado. Frisou que pagou R\$ 1.000 ou R\$ 800 na droga e a usaria em duas semanas, pois fumava dia e noite sem parar. Afirmou que tinha R\$ 800 no bolso fora a droga. Relatou que tinha vendido parte do terreno e pediu ao comprador para adiantar R\$ 2.500, para pagar água e luz, mas ao invés foi para Assis pegar drogas para fumar. Mencionou que é dependente químico e já falou para os parentes que precisava internação. Negou vender drogas, nunca vendeu. Frisou que não compra em Florínea porque saiu há pouco tempo da cadeia, eles são usuários, a cidade é pequena e a maioria das pessoas é trabalhadora. Contou que um primo seu foi em sua casa perguntar se o interrogando vendia drogas e disse a ele que não fazia isso. Falou que nas outras vezes também comprou drogas em Assis, quantia para duas semanas, às vezes não dá nem para isso. Negou conhecer o policial Marcelo Maciel. Esclareceu que a pessoa que vai em casa é seu cunhado, pessoas vão levar alimentos lá. Disse que na delegacia falou que é usuário e que o pacotinho estava nessa forma porque é assim que vendem. Negou ter sido hospitalizado depois da cadeia, por causa do Coronavírus. Frisou que desde criança sofre perseguição policial porque bebia e começou a usar esses negócios, brigava na rua, ameaçaram lhe arrumar um tráfico. Enfatizou que quer tratamento. Admitiu que foi acusado de tráfico, assalto e injustamente de ter agredido a ex esposa.

A testemunha Luciano afirmou ter informações de que o réu morava em Florínea, vinha para Assis comprar drogas para revender naquela localidade. Relatou que o abordou e encontrou na cueca do Gilson crack e maconha divididas em porções, também celular e seiscentos e poucos reais. Mencionou que pela rede de rádio foi falado sobre o Gilson, de camiseta vermelha e calça jeans, que veio buscar drogas para revender em Florínea. Negou conhecer o réu, mas ele estava proibido de sair de Florínea porque tinha saído a pouco tempo da prisão. Negou que o réu trouxesse petrecho utilizado para usar entorpecentes. Disse que ele ficou calado com relação ao dinheiro e se eram para uso ou mercancia. Frisou que os policiais falaram que o réu vendia drogas na casa dele, pela janela da casa. Esclareceu que a casa é de difícil acesso e não lograram êxito em prender ele por lá. Declarou que é difícil conseguir testemunha em casos como este. Negou que a outra testemunha tenha assistido seu depoimento na Delegacia.

Tais fatos foram confirmados pelo policial Bruno. Acrescentou que essa abordagem foi na Av. Davi Passarinho, defronte a uma padaria. Falou que ele estava sozinho, porém tinha pessoas no mototáxi ao lado. Declarou que ele demonstrou nervosismo e inquietação com a presença da polícia. Narrou que localizou crack e maconha na cueca do réu, em embalagens individuais. Negou conhecê-lo dos meios policiais. Negou que o outro policial tenha escutado seu depoimento na delegacia. Negou que o réu tenha dito se era viciado. Informou que a denúncia falava que o réu vendia drogas pela janela e comprava drogas em Assis para revender. Negou saber se o réu foi preso em Florínea traficando, mas sabe que tem passagens criminais. Negou que o réu aparentasse estar drogado naquele momento.

A testemunha Valéria negou saber dos fatos, sabe que o réu é usuário de drogas. Afirmou que trabalha na área da saúde como técnica de enfermagem. Relatou que já atendeu o réu, ele procurou por problemas de alergia e no dente, foi quando conversou com ele, ele era usuário e não falava coisa com coisa. Mencionou que conhece o Gilson desde seus 12 anos, antigamente ele trabalhava por dia e cortava cana, carpia soja, depois foi preso e não trabalhou mais. Narrou que ele usava qualquer droga que tinha, ele falou que usava maconha e crack. Confirmou que o réu falou sobre a busca de tratamento e o orientou a procurar a assistência social. Falou que ele tinha aparência de usuário, olho estalado, vermelho, bem drogado. Disse parecer que a família dele estava vendendo uma chácara. Declarou que sempre tem usuários de drogas em Florínea, pelos comentários tem pessoas que vendem na cidade, não sabe quem.

A testemunha Ercília afirmou saber que o réu é usuário e o vê drogado na rua. Relatou que o conhece há 15 anos e não trabalha. Negou saber qual droga ele usa. Mencionou que ele se sustenta com a venda de uma chácara de herança, não sabe qual o valor da venda, eram 8 irmãos. Narrou que já o viu algumas vezes drogado e o réu

já lhe disse precisar de tratamento. Negou o ter visto vendendo drogas. Esclareceu que percebe que ele está drogado pelo jeito de falar e andar. Frisou que o réu disse que o dinheiro da chácara é o que ele tem. Negou ver drogas no local onde moram e na cidade, mas existe vários pontos de droga pelo que ouviu falar.

A testemunha Maria Carolina negou ter ouvido falar sobre os fatos. Relatou que é amiga do réu há mais de dez anos. Mencionou que ele não trabalha. Falou que ele é usuário de drogas, não sabe o tipo, já o viu estranho na rua. Negou tê-lo visto vendendo drogas em Florínea. Disse que ele havia saído da cadeia há uns 3 ou 4 meses. Contou que o pessoal tem medo dele porque o vê drogado na rua. Narrou ter ouvido comentário na cidade que ele se sustenta com o dinheiro da venda de uma chácara, acha que há uns 3 ou 4 meses. Esclareceu que na verdade é um terreno herança de família e conhece o comprador.

Pois bem. O tráfico de drogas se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e antecedentes do agente.

De acordo com a prova testemunhal produzida, policiais militares tinham a informação de que Gilson viria até a cidade de Assis comprar drogas para revendê-las na cidade de Florínea e a descrição da roupa que ele usava no dia dos fatos. Abordaram o réu e durante a revista encontraram em sua cueca 50,58 g de crack e 23,69 g de maconha. Também fizeram a apreensão de um telefone celular e cerca de seiscentos reais.

A identidade dos depoimentos dos policiais que abordaram o réu não retira a credibilidade deles, mas servem para confirmação recíproca. Tal convergência é esperada, considerando que as testemunhas presenciaram o mesmo fato. Do contrário, a prova oral perderia consistência. Os policiais afirmaram que não foram ouvidos um na presença do outro e percebe-se, nos depoimentos deles em Juízo, que não foram idênticos entre si.

Oportuno ressaltar que o réu, quando interrogado na Delegacia de Polícia, estava acompanhado pelo Advogado Dr. Walter Silveira e, naquela oportunidade, não alegou irregularidade nos registros dos depoimentos dos policiais.

Ademais, não há qualquer prova concreta a indicar parcialidade dos policiais e verifico que eles sequer conheciam o réu, que residia em outra cidade.

A expressiva quantia de droga transportada pelo réu, aliada à informação trazida pelos policiais de que havia denúncias de que Gilson comercializava entorpecentes em sua casa, consistem em elementos suficientes para amparar a condenação pelo crime do art. 33.

Cada pedra de crack pesa cerca de 0,25g, segundo a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, relatório II Núcleo de Pesquisa em Criminologia e Política Penitenciária - NUPECRIM

(Relatório_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tráfico_-_NUPECRIM-PR.pdf (tjmt.jus.br)). Tomando essas informações por base, o réu poderia fracionar a porção de crack em mais de 200 pedras e não é verossímil que ele usaria tudo em duas semanas como disse em Juízo. Portanto, forçoso concluir que os entorpecentes se destinariam também ao uso de terceiros .

Destaco que o réu é reincidente específico já foi condenado duas vezes por tráfico de drogas. Apesar do passado do agente não constituir prova, pode reforçar convicções quando evidencia que o ato incriminado é simples rotina na vida do acusado (RT 564/393).

Ainda que Gilson e as testemunhas arroladas pela Defesa tenham confirmado a condição de usuário, isso não implica no automático reconhecimento de que era

dependente e que fazia uso abusivo de entorpecentes. Na perícia realizada para aferir a dependência química do réu (fls. 71/75 dos autos apensos) o perito concluiu pela sua imputabilidade, atestando que ele era capaz de discernir a ilegalidade da conduta e que, apesar de ser usuário contumaz de entorpecentes, não desenvolveu transtorno mental ou comportamental:

Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame físico e psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que o periciado não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID, DSM, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado incapacitante ou incompleto, doença mental, transtorno psíquico ou emocional, nem de qualquer outro distúrbio suficiente para alterar a capacidade de julgamento, nem há referências pregressas, demonstrando prejuízo da integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação.

Cabe esclarecer que se trata de pessoa usuária contumaz de drogas, porém que não desenvolveu transtorno mental/comportamental em decorrência deste uso tampouco desenvolveu distúrbio ou perturbação de sua saúde mental. Em nenhum momento apresentou síndrome de abstinência, sintomas de privação de uso ou sinais de tolerância às drogas; também não apresentou comprometimento de sua saúde física e/ou mental, nem de seus relacionamentos familiares, sociais, afetivos, culturais ou laborativos em decorrência do uso de álcool e/ou drogas, assim sendo, não preenche os critérios diagnósticos para dependência de substâncias psicoativas relacionados e especificados nos mesmos ditames técnicos e científicos (CID-10, DSM-V, OMS e OPAS).

Não apresenta ausência ou diminuição da pilosidade nasal ou lesões físicas, que estariam obrigatoriamente presentes em caráter permanente, em decorrência da quantidade, frequência e tempo de uso de drogas alegado (critérios físicos), não havendo, portanto, dependência de álcool ou drogas, sendo considerado, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, IMPUTÁVEL para o delito descrito na denúncia. Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar.

A douta Defesa afirma que a demora de mais de um ano na realização da perícia implicou em cerceamento de defesa porque o réu não estava mais sob efeito de drogas na época do exame. Contudo, não houve cerceamento de defesa porque foi imediatamente deferida a produção da perícia. A demora na realização do exame pelo IMESC não é responsabilidade deste Juízo, que cobrou várias vezes a perícia (fls. 24, 30, 37/44, 48/60 e 63 dos autos apensos).

Ainda que o réu Gilson seja usuário, não era justificável trazer consigo tanta droga e não há comprovação de que havia compulsão tão grande que justificasse comprar tanto de uma vez. Sabe-se que, não raro, usuários de drogas acabam atraídos para o comércio nefasto até como uma forma de subsidiar o vício. Porém, a desclassificação pretendida só é admitida quando se comprove que a posse do entorpecente se destina, exclusivamente, a consumo próprio, situação que não se verifica neste caso concreto. As evidências de que existiram atos ilícitos de posse para mercancia não podem ceder lugar para a posse de drogas para uso próprio. O réu pode até ser usuário de drogas, mas deve prevalecer, para fins penais, no caso em tela, a conduta descrita no tipo que define o crime de tráfico, mais gravosa perante a sociedade, por não ter sido provado que as drogas eram destinadas exclusivamente ao uso próprio. Assim, não é possível desclassificar a conduta para o porte de drogas para o uso próprio.

Por outro lado, não é caso de decretar o perdimento do dinheiro apreendido, pois os documentos de fls. 198/202 e os depoimentos das testemunhas de Defesa corroboram a alegação do réu de que ele vendeu um terreno que herdou dos seus pais e que o numerário em questão teria advindo do referido negócio. Assim, é o caso de restituí-los ao requerido. Também cabe devolver o telefone celular apreendido com o réu porque não há prova de que foi usado para a prática delituosa aqui apurada, conforme relatório de fls. 231/236.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente:

Consoante a inteligência do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena (STF, HC 127241/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado 04-08-2015, STF, RHC 117489/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 18-06-2013) e constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STF, RHC 122598, Rel. Min. Teori Zavaski, julgado em 14-10-14). A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevadíssima intensidade pela variedade e pela grande quantidade de droga apreendida (cerca de 50 g de crack e 23 g de maconha). Além do caráter extremamente nocivo do crack, droga altamente lesiva pelo grande poder de viciar seus usuários. A vultosa quantidade e a variedade do entorpecente apreendido revelam o dolo exacerbado a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, possibilitando a circunstância ao agente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias. O réu é reincidente específico, tem mais uma reincidência e ostenta outras duas condenações antigas transitadas em julgado (fls. 55/61), podendo uma destas ser consideradas como Maus Antecedentes sem caracterizar *bis in idem* por se tratar de fatos distintos. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como Maus Antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. De acordo com o entendimento, o instituto dos Maus Antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), na sessão virtual encerrada em 17/8/2020. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “O conceito de Maus Antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como Maus Antecedentes” HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016. Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017” (STJ, AgRg no HC 455.563/MS, 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer, j. 18/10/2018). Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo.

Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes a considerar. Presente a agravante da reincidência. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que: “o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente” (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto a reincidência é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e persistiu na senda do crime.

O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração da pena maior que a natural em casos como este, pois tal prática “demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa”. No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA

REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 101.918/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 11.05.2010, unânime, DJe 04.06.2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se:

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014, destaquei)”.

Dessa forma, é viável majorar a pena em 1/3 pela reincidência específica. Reconheço a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada no julgamento de traficante pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública” (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei).

Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, “se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Somando as duas agravantes aumento a pena em 1/2 (metade), alcançando 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa. Na terceira fase não há causas de aumento e nem de diminuição da pena. Ressalto que a reincidência e os péssimos antecedentes tornam inaplicável a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Isso porque demonstrou que não era traficante ocasional. Pelo contrário, é criminoso habitual e não merece

a benesse. Assim, atinge a pena o montante final de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório e do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como da reincidência e dos píssimos antecedentes. Tal situação e o montante da pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direito e a concessão da suspensão condicional da pena. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Pelo art. 1º: “a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei”. Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Neste caso concreto o réu somente faria jus à progressão de regime após o cumprimento de 3/5 da pena, o que não aconteceu. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante ainda será o fechado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Gilson Martins, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita porque se trata de réu pobre.

Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar e mantinha posse de grande quantia de droga, a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis:

“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

“(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...)” (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei).

Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Expeça-se mandado de levantamento judicial do valor apreendido em favor do réu; 5) Se o advogado tiver poderes para receber e indicar conta bancária, oficie-se ao Banco do Brasil solicitando que efetue a transferência para a conta indicada pelo réu e envie comprovante nos autos; 6) Expeça-se ofício autorizando a entrega do celular ao réu ou pessoa por ele autorizada, no prazo de 90 dias, sob pena de destruição do aparelho; 7) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 8) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que: a) retire o celular apreendido, por si ou representante, no prazo de 90 dias, sob pena de destruição; b) pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 9) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 15) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

Assis, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA